

NOOR AZRIN BINTI ABD. RAZAK

lwn.

SAIFUL JOHARI BIN AHMAD

[Mahkamah Rayuan Syariah Shah Alam Di Selangor, YAA Prof. Adjung Dato' Dr. Hj. Mohd Nai'm Bin Mokhtar (Pengerusi), Y.A Tn. Hj. Mohd Amran Bin Hj. Mat Zain (Panel), YA Dato' Hj. Mohd. Shukor bin Sabudin (Panel) Pada 5 April 2019 bersamaan 29 Rejab 1440H]

[Kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0154-2018]

[Permohonan Semakan di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Pemohon : Tn. Hasrul Fahmi Bin Jamaluddin daripada Tetuan Hasrul Fahmi & Associates.

Peguam Responden : Tidak diwakili.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon pada 12/12/2018 bagi menyemak keputusan / perintah yang telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam Selangor pada 13/11/2018 di dalam kes Permohonan No. : 10400-038-0351-2018.

[2] Pemohon memfailkan permohonan semakan ini adalah untuk mendapatkan suatu perintah sepertimana berikut –

- (a) Bahawa Mahkamah Yang Mulia ini memanggil dan menyemak rekod-rekod dan perjalanan kes Permohonan Hak Jagaan Sementara ke atas tiga orang anak yang bernama Alif Danial Bin Saiful Johari, Siti Aisyah Binti Saiful Johari dan Nur Amani Binti Saiful Johari melalui Permohonan No. : 10400-038-0351-2018;
- (b) Bahawa Mahkamah Yang Mulia ini memanggil dan menyemak keputusan yang diputuskan oleh Hakim Bicara pada 13/11/2018.
- (c) Apa-apa perintah atau relif lain yang suai dan manfaat yang difikirkan patut dan wajar oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

[3] Permohonan semakan ini difailkan bersama-sama Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan bertarikh 12/12/2018. Alasan permohonan semakan Pemohon adalah diringkaskan sebagaimana berikut -

- a) Sebagai ibu kandung, Pemohon adalah orang yang berhak dan layak menjaga anak-anak tersebut di sisi Hukum Syarak demi kemaslahatan anak-anak tersebut;
- b) Pemohon berkemampuan untuk menjaga anak-anak tersebut serta dapat memberi tumpuan penuh dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;

- c) Mahkamah harus mempertimbangkan kebajikan dan emosi anak-anak tersebut sekiranya tinggal bersama dengan Responden kerana anak-anak tersebut dijaga oleh isteri Responden yang mempunyai anak-anak lain dari perkahwianannya yang terdahulu; dan
- d) Anak-anak tersebut telah melepasi hak umur bagi maksud hak penjagaan kanak-kanak mengikut Hukum Syarak dan Undang-Undang dan anak-anak tidak dipanggil untk hadir ke Mahkamah bagi menyatakan keinginan untuk tinggal bersama Pemohon atau Responden memandangkan anak-anak tersebut telah mencapai umur mumaiyiz.

FAKTA KES

[4] Pemohon dan Responden telah bernikah pada 24/2/2002 dan telah bercerai pada 22/11/2011. Hasil perkahwinan, mereka dikurniakan seorang anak lelaki dan tiga orang anak perempuan.

[5] Responden telah memfailkan permohonan Hak Jagaan Anak Sementara bagi tiga orang anak iaitu Alif Danial Bin Saiful Johari (15 tahun), Siti Aisyah Binti Saiful Johari (14 tahun) dan Nur Amani Binti Saiful Johari (10 tahun). Pada 13/11/2018, YA Hakim Bicara telah memutuskan –

- i. Mahkamah meluluskan permohonan Pemohon berdasarkan seksyen 201 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
- ii. Mahkamah memerintahkan hak jagaan sementara ke atas 3 orang anak yang bernama Alif Danial Bin Saiful Johari, Siti Aisyah Binti Saiful Johari

dan Nur Amani Binti Saiful Johari hendaklah diserahkan kepada Pemohon (bapa) sehingga kes induk hak jagaan anak melalui kes Saman No. : 10400-028-0928-2017 diluluskan.

- iii. Mahkamah memerintahkan Responden (ibu) hendaklah diberikan hak lawatan dan bersama anak-anak tersebut pada bila-bila masa yang munasabah dengan memaklumkan terlebih dahulu kepada Pemohon.

[6] Oleh kerana Pemohon tidak berpuashati dengan keputusan tersebut, Pemohon telah memfailkan semakan ini pada 12/12/2018.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[7] Sukacita kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[8] Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 68 Enakmen

Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003. Di samping itu juga, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes *Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah*, JH 36 (2), kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes *Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

[9] Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[10] Bagi melaksanakan semakan ini, kami telah memanggil dan menyemak rekod kes Permohonan No. : 10400-038-0351-2018. Penelitian terhadap fail atau rekod kes tersebut sangat penting kerana proses semakan ialah untuk mengenalpasti apakah adanya apa-apa kecacatan sepanjang perbicaraan atau

kecacatan terhadap mana-mana perintah sama ada kecacatan dari segi undang-undang atau kekhilafan Hukum Syarak.

[11] Kami dapati bahawa kes tersebut telahpun selesai dan diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam Selangor, di mana YA Hakim Bicara telah memutuskan perintah sepertimana perenggan 5 (i hingga iii). Kedua-dua pihak tidak diwakili oleh mana-mana Peguam Syarie semasa prosiding kes tersebut. Anak yang menjadi isu di dalam kes ini iaitu Alif Danial Bin Saiful Johari telah berumur 15 tahun, Siti Aisyah Binti Saiful Johari berumur 14 tahun dan Nur Amani Binti Saiful Johari berumur 10 tahun.

[12] Setelah Responden (Pemohon kes ini) diserahkan Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan Pemohon (Responden kes ini), beliau telah memfailkan Afidavit Jawapan pada 14/9/2018. Pada sebutan bertarikh 19/9/2018, Pemohon (Responden kes ini) telah diarahkan untuk memfailkan Afidavit Balasan sebelum / atau pada 10/10/2018 dan kes ditangguhkan untuk keputusan pada 13/11/2018. Pemohon (Responden kes ini) tidak memfailkan Afidavit Balasan seperti yang diarahkan dan keputusan telah dibacakan oleh pada 13/11/2018 tanpa kehadiran Responden.

[13] Bagi kes ini, kami dapati bahawa umur anak-anak yang menjadi isu pertikaian di dalam kes tersebut telah mencapai umur mumaiyyiz sepertimana peruntukan seksyen 85 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 [EUUKIS 2003] yang menyatakan –

- (1) *Hak hadinah bagi menjaga seseorang kanak-kanak adalah tamat setelah kanak-kanak itu mencapai umur tujuh tahun, jika kanak-kanak itu lelaki,*

dan umur sembilan tahun, jika kanak-kanak itu perempuan, tetapi Mahkamah boleh, atas permohonan hadinah, membenarkan dia menjaga kanak-kanak itu sehingga kanak-kanak itu mencapai umur sembilan tahun, jika kanak-kanak itu lelaki, dan umur sebelas tahun, jika kanak-kanak itu perempuan.

- (2) Setelah tamatnya hak hadhanah, penjagaan turun kepada bapa, dan jika kanak-kanak itu telah mencapai umur kecerdikan (*mumaiyyiz*), maka kanak-kanak itu adalah berhak untuk memilih untuk tinggal dengan sama ada ibu atau bapanya, melainkan jika Mahkamah memerintahkan selainnya.

[14] Apabila suatu permohonan untuk mendapat perintah interim hadhanah secara inter-parte berdasarkan peruntukan seksyen 201 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 dipohon, maka ia juga perlu merujuk kepada peruntukan asal berkaitan dengan *hadhanah* berdasarkan seksyen 82 dan / atau 85 EUUKIS 2003.

[15] Berdasarkan subseksyen 85 (2) EUUKIS 2003, anak-anak tersebut telah melepasi tempoh jagaan (*hadhanah*) dan anak-anak tersebut sewajarnya diberi hak untuk membuat pilihan untuk tinggal dan bermalam kerana telah melepasi kewajipan *hadhanah*. Pendekatan peruntukan subseksyen 85 (2) EUUKIS 2003 untuk mendengar pendapat dan juga pemilihan anak-anak tersebut ini adalah berasaskan kepada alasan berikut -

قال الشافعي : فاذا افترق الأبوان وهما في قرية واحدة فالأم أحق بولدها ما لم تتزوج وماكانوا صغارا فاذا بلغ أحدهم سبعا أو ثمانا سنين وهو يعقل خير بين أبيه وأمه وكان عند أيهما اختار

Maksudnya : As-Shafie berkata: “Apabila berpisah kedua ibu bapa dan kedua-duanya berada dalam satu qariah maka ibu adalah lebih berhak terhadap anaknya selama ia belum berkahwin lain dan semasa anak-anak itu masih kecil. Apabila genap umur mereka tujuh tahun atau lapan tahun dan ia sempurna akal ia disuruh pilih di antara bapa dan ibunya dan ia akan bersama dengan siapa yang dipilih.”(Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris, Al-Umm, Juzu’ 5, hlm. 99)”

[16] Menurut kitab “الحضانة وأثرها في تنمية سلوك الأطفال في الفقه الإسلامي” karangan Prof. Dr. Abdul Mutthalib Abdul Razzak Hamdan seorang Pensyarah di Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Al-Azhar Mesir, hlm. 73, menukulkan pandangan ulama As-Syafieyyah daripada kitab *Mughni Al-Muhtaj, Nihayah Al-Muhtaj* dan *Hasyiah Al-Jamal* seperti katanya -

فعند الشافعية : يخير المحضون إذا ميز ، والتميز أن يستقل بأمور نفسه من الأكل والشرب ونحوه ، ولا عبء بالبلوغ سبع سنين ن فلو جاوز السبع بلا تمييز فإنه يبقى عند أمه ، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى

Maksudnya : “Menurut ulama as-Syafieyyah ; kanak-kanak diberi pilihan untuk tinggal sama ada dengan ibunya atau dengan bapanya apabila ia sudah mumaiyyiz. Maksud Mumaiyyiz ialah kanak-kanak itu boleh melakukan perbuatan tersebut dengan sendirinya seperti makan, minum dan sebagainya, jika sekiranya umur kanak-kanak itu melebihi tujuh tahun tetapi tidak mumaiyyiz maka hak penjagaan kepada ibunya, yang sedemikian tidak ada beza di antara kanak-kanak itu lelaki atau perempuan”

[17] Apabila anak itu sudah *mumaiyyiz*, maka ia boleh membuat pilihan sama ada hendak tinggal dengan ibunya atau dengan bapanya, ini berdasarkan Hadis Rasulullah s.a.w iaitu -

عن ابي هريرة رضى الله عنه قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني ، وقد سقاني من بئر أبي عتبة ، وقد نفعتني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إستهما عليه) فقال زوجها : من يحاقني في ولدي ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (هذا أبوك ، وهذه أمك ، فخذ بيد أيهما شئت) فأخذ بيد أمه ، فانطلقت به .

"Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a katanya; Telah datang seorang perempuan kepada Rasulullah s.a.w seraya berkata: "Wahai Rasulullah s.a.w sesungguhnya suamiku hendak membawa anakku bersamanya, sedangkan anakku telah menolongku mengambil air daripada telaga Abi 'Itabah (أبي عتبة) (iaitu sebuah telaga di Madinah Munawwarah) dan anakku banyak memberi faedah kepadaku daripada pertolongannya itu. Maka Sabda Rasulullah s.a.w; Hendaklah kamu berdua membuang undi tentang anak kamu, maka suaminya itu menjawab "Siapakah yang boleh menghalang hakku tentang anakku ini." Lalu Baginda Rasulullah s.a.w berkata kepada anak itu agar membuat pilihan sama ada ingin tinggal dengan ibunya atau mengikut bapanya dengan sabdanya; "Ini bapa kamu dan ini juga ibu kamu, maka pilihlah siapa di antara kedua-duanya yang engkau suka tinggal bersama". Maka anak itu pun memilih ibunya dengan memegang tangan ibunya itu, lalu perempuan itu pun membawa anaknya itu pulang bersamanya" (Riwayat Abu Daud 2/ 283 Kitab Al-Talaq).

[18] Menurut pandangan Imam Muhammad Bin Ismail Al-Yamani As-Shon'aani di dalam kitabnya *Subul As-Salam*, jilid 3, hlm. 228 -

فقد دل الحديث على أنه بعد إستغناء الصغير بنفسه ، يخير بين أبويه

“Hadis di atas menunjukkan bahawa kanak-kanak yang sudah boleh menguruskan dirinya dengan sendiri diberi pilihan untuk tinggal dengan salah seorang daripada kedua ibubapanya”

[19] Imam Ibnu al-Qaiyyim di dalam kitabnya *A’lam Al-Muwaqqi’in*, jilid 2, hlm. 249 berkata -

تخير الولد بين أبويه ثابت بالسنة الصحيحة المحكمة

“Hak pemilihan anak untuk tinggal sama ada dengan ibunya atau dengan bapanya ada sabit terdapat di dalam sunah yang sahih”

[20] Berdasarkan rujukan di atas, Mahkamah perlu melakukan ujian bagi menentukan sama ada anak-anak tersebut telah *tamyiz / mumaiyyiz* ataupun tidak. Ujian yang dimaksudkan di dalam otoriti di atas memerlukan Mahkamah menemubual anak-anak tersebut dan mengetahui pilihan dan alasannya untuk memilih *hadhinah* atau *hadinnya*.

[21] Bagi kes Permohonan No. : 10400-038-0351-2018, kami dapati bahawa YA Hakim Bicara tidak memanggil atau menemubual anak-anak tersebut yang telah melangkaui umur *mumaiyyiz* sebelum keputusan dibuat. YA Hakim Bicara juga di dalam penghakimannya tidak menjustifikasikan tindakan beliau yang tidak memanggil atau menemubual anak-anak tersebut sebelum pertimbangan dan keputusan dibuat. Oleh yang demikian, kami berpuashati bahawa tindakan YA Hakim Bicara ini jelas bertentangan dengan kehendak undang-undang dan Hukum Syarak.

[22] Kami juga dapati bahawa semasa keputusan dibacakan oleh Pendaftar, Responden (Pemohon kes ini) direkodkan tidak hadir. Pemohon (Responden kes ini) tidak diminta untuk melafaz *Yamin Istizhar* sebelum keputusan tersebut dibacakan berdasarkan peruntukan seksyen 121 ETMMSS 2003 –

Seksyen 121 -Ketakhadiran pihak-pihak

- (1) *Jika, apabila mana-mana tindakan dipanggil untuk pendengaran –*
 - (a) *tiada satu pihak pun hadir, Mahkamah boleh membuang tindakan itu;*
 - (b) *defendan tidak hadir, Mahkamah boleh, tertakluk kepada bukti penyampaian wajar, mendengar dan memutuskan tindakan itu tanpa kehadirannya; atau*
 - (c) *plaintif tidak hadir, Mahkamah boleh membuang tindakan itu dan mendengar memutuskan apa-apa tuntutan balas.*
- (2) *Mahkamah hendaklah, sebelum membuat apa-apa penghakiman mengenai tuntutan plaintif di bawah perenggan (1)(b) atau tuntutan balas defendan di bawah perenggan (1)(c), mengarahkan plaintif atau defendan, mengikut mana-mana yang berkenaan, mengangkat sumpah istizhar.*

[23] Berdasarkan dapatan-dapatan yang kami perolehi terhadap prosiding permohonan perintah interim hadhanah inter-parte kes Permohonan No. : 10400-038-0351-2018, kami berpuashati bahawa keputusan yang telah dikeluarkan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam tidak tepat dari segi undang-undang dan Hukum Syarak. Perkara ini secara tidak langsung mewajarkan kami untuk campurtangan bagi mengenepikan keputusan tersebut.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan Pemohon, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

- [1] Permohonan semakan Pemohon adalah **DITERIMA**.
- [2] Keputusan kes Permohonan No. : 10400-038-0351-2018 bertarikh 13/11/2018 adalah **DIBATALKAN**.
- [3] Mahkamah memerintahkan supaya anak-anak di dalam kes Permohonan No. : 10400-038-0351-2018 dipanggil untuk ditemubual sebelum pertimbangan dan keputusan akhir dibuat.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



.....
1. **Y.A.A PROF. ADJUNG 'DATO' DR. HJ. MOHD NAI'M BIN MOKHTAR**

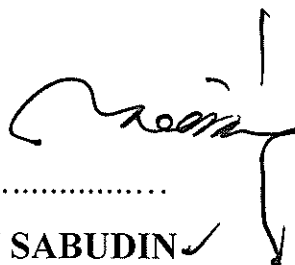
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



2. **Y.A TN. HJ. MOHD AMRAN BIN HJ. MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



3. **Y.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN** ✓
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

